

1500525-20.2020.8.26.0223

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500525-20.2020.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500525-20.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2022643/2020 - 01º D.P. GUARUJA, 6063492 - 01º D.P. GUARUJA, 372/19/219 - 01º D.P. GUARUJA, 2022643 - 01º D.P. GUARUJA, 372/19/219 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DOMINGUES FAGUNDES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Robson Domingues Fagundes, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de abril de 2019, pelo período da manhã, na Rua Tartarugas, nº 90, Pae Cará, nesta cidade e Comarca de Guarujá, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3,7 litros de cloro de metileno/diclorometano, substância entorpecente vulgarmente conhecida como "lança-perfume", conforme laudo toxicológico de fls.20/24, de caráter ilícito e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 20/24).

O réu foi notificado (fls.57) e apresentou defesa prévia (fls.68/72), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls.83/84).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e o réu interrogado (fls.120/121). Foi declarada encerrada a instrução e pelas partes não foram requeridas diligências (fls.122).

O representante do Ministério Público, nos debates, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls.122/124).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, com a redução no patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls.127/129).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 20/24, bem como pela prova oral coligida nos autos. A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu confessou os fatos. Disse que do dia dos fatos, por volta das 06:30 horas, encontrava-se em sua residência (Rua Tartarugas, nº 90, Bairro Pae Cara), quando chegaram policiais civis com mandado de busca e apreensão. Os policiais perguntaram se havia alguma droga na residência e o interrogando disse que havia "Lolo". Realizaram buscas na residência e o interrogando disse que o "Lolo" estava no guarda-roupas, na geladeira, e em um galão ao lado da geladeira. Foram apreendidos vários frascos pequenos com "Lolo" dentro do guarda-roupas e mais uma sacola com 07 (sete) frascos plásticos contendo "Lolo" dentro da geladeira. Vende cada frasco plástico com "Lolo" a cinco reais. O galão com "Lolo" seria dividido em frascos pequenos também para serem vendidos a cinco reais cada frasco. Estava vendendo "Lolo" há um mês e meio aproximadamente, pois estava desempregado. Comprou um galão de "Lolo" de um indivíduo desconhecido que estava vendendo no Bairro Pae Cara. Pagou a importância de cem reais no galão. Após dividir o galão em frascos pequenos, iria render aproximadamente trezentos ou quatrocentos reais (fls. 08).

No entanto, em juízo, o réu mudou a sua versão.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Disse que na época dos fatos não residia no local em que a droga foi apreendida. Estava no imóvel ao lado, pois fazia manutenção na casa. Escutou um barulho e foi ver do que se tratava. Os policiais "estouraram o portão" e entraram. Foi puxado pelos policiais para dentro da residência e algemado. Em seguida, os policiais iniciaram as buscas no imóvel. Havia um inquilino no imóvel (chamado Rafael), mas ele estava ausente no momento em que as buscas foram realizadas. Confessou os fatos na delegacia pois os policiais disseram que "ele era o responsável e tinha que assumir como se fosse o dono". Não acompanhou as buscas realizadas no imóvel (fls.125/126).

Pois bem, na fase extrajudicial o réu confessou a prática do delito e, em juízo, o réu modificou sua versão, passando a negar a prática delitiva. Entretanto, deve prevalecer a confissão extrajudicial do réu, que restou corroborada pelas demais provas dos autos. As provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva do réu e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial civil Nei Gomes de Andrade, no seu depoimento judicial, narrou que realizaram investigação preliminar antes de solicitarem mandado de busca e

apreensão para o imóvel do réu. A investigação constatou que o local era ponto de tráfico de drogas e receptação de objetos de origem ilícita e armamento. Na data dos fatos cumpriram mandado de busca e apreensão (no período da manhã) e foram recepcionados pelo réu. Questionaram ao réu se havia algo ilícito no local e o réu afirmou que havia “Lolo”. Durante as buscas localizaram 86 frascos individualizados contendo “lança-perfume” e um galão de aproximadamente 3 litros contendo “o mesmo entorpecente”. Os entorpecentes foram localizados na cozinha e no quarto. O réu admitiu que vendia cada frasco pelo valor de R\$5,00 (cinco reais) e que estava traficando há cerca de um mês e meio porque estava desempregado. Foi conduzido para a delegacia, mas não foi autuado em flagrante pois na data dos fatos não puderam fazer a constatação da substância entorpecente. O mandado foi cumprido no local em que o réu residia. Quando chegaram na residência, o réu “tinha acabado de acordar”. Não conhecia o réu anteriormente (fls.125/126).

Raphael Ramos Jacovani, policial civil, em juízo, disse que no dia dos fatos cumpriram mandado de busca e apreensão no imóvel e tiveram a entrada franqueada pelo réu. Indagado, o réu afirmou que havia frascos de “lança perfume” (lolo) na residência e indicou o local em que os entorpecentes se encontravam (próximo à geladeira e no guarda-roupas). Localizaram no imóvel um galão “de quase 4 litros” e 86 frascos contendo “lança-perfume”. Nada mais foi encontrado. O réu foi conduzido à delegacia. Não se recorda se tinham mais casas no terreno. Não conhecia o réu anteriormente (fls.125/126).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

“[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,[...]”.(STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

“[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]” (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais, da prova material apreendida e da confissão extrajudicial do réu, sem dúvida o réu tinha em depósito os entorpecentes apreendidos e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros.

Tem-se que diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, diante da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, em embalagens individualizadas e em galão contendo vários litros do mesmo entorpecente, restou comprovada a conduta típica do réu narrada na inicial acusatória.

Importante mencionar que o fato da confissão do réu ter ocorrido apenas em fase extrajudicial não afasta seu valor probatório, pois a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, bem como pela prova material. Com efeito, a confissão extrajudicial não pode ser descartada quando confirmada pelo restante do conjunto probatório.

Ressalto que o depoimento da testemunha de defesa não foi capaz de afastar a conduta típica praticada pelo réu.

Paula Barcelos Nunes dos Santos, em juízo, disse que conhece o réu há onze anos. Afirmou que Robson “toma conta” do local em que ocorreram os fatos, mas nunca morou no imóvel. Trata-se de um “imóvel de família” que é alugado. Existem várias casas no local. Robson sempre foi uma pessoa boa, sempre trabalhou. Ficou surpresa quando soube dos fatos. Não presenciou os fatos (fls.125/126).

Pois bem, a testemunha Paula afirmou que o réu não reside no local dos fatos. Porém, não presenciou os fatos. A seu turno, os policiais afirmaram que foram

recebidos no local pelo réu e o réu tinha acabado de acordar. Portanto, devem prevalecer os depoimentos dos policiais, pois não foi apresentada qualquer situação a demonstrar que seus depoimentos não merecem credibilidade, destacando que o réu confessou a autoria dos fatos na fase policial. Logo, o depoimento da testemunha de defesa restou isolado nos autos.

Dessa forma, deve prevalecer a conduta típica praticada pelo réu.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o réu tinha em depósito os entorpecentes e que os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados ao consumo de terceiros. Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada, pois ausentes circunstâncias modificadoras. Destaco que deixo de reduzir a pena ante a confissão extrajudicial tendo em vista que a atenuante não pode levar a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o acusado preenche os requisitos legais previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois é primário e não existem indícios de que integra organização criminosa. Assim, preenchidos os requisitos legais, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes (86 frascos e 01 galão de "lança-perfume" - fls.06), aplico a causa de diminuição e reduzo a reprimenda em 2/3, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Neste sentido a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Cumprir destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena, pois não se mostra medida suficiente e adequada ao presente caso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Robson Domingues Fagundes para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à Autoridade Policial determinando-se a destruição da contraprova.

Defiro a gratuidade de justiça ao réu. Anote-se.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Guaruja, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA